

1502220-23.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502220-23.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502220-23.2022.8.26.0228, c. 149/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023155/2022 - 08º D.P. BRAS, 22649870 - 08º D.P. BRAS, 202/22/108 - 08º D.P. BRAS, 2023155 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETRONIO EMIDIO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

RODRIGO DOS SANTOS CHAVES e PETRONIO EMIDIO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. os artigos 29, caput, e 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 00h35, na Rua Sinimbu, altura do numeral 200, Liberdade, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 46 (quarenta e seis) porções de Cannabis Sativa L prensada, contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como maconha, com massa líquida de 92,1g (noventa e dois grama e um decigrama), 61 (sessenta e um) invólucros de

cocaína, com massa líquida de 17,1g (dezesete gramas e um decigrama), bem como 124 (cento e vinte e quatro) porções de crack, com massa líquida de 24,0g (vinte e quatro gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 31 de janeiro de 2022.

Em 03 de fevereiro de 2022, houve a determinação para a notificação do réu, bem como a apresentação da defesa prévia (fls. 137/141).

Os réus foram notificados às fls. (Rodrigo) e fls. (Petrônio) e ofertaram defesas preliminares (Rodrigo - fls. 212 e Petrônio - fls.). A denúncia foi recebida (Rodrigo - fls. 219 e Petrônio - fls.) e os réus foram citados pessoalmente (Rodrigo - fls... e Petrônio - fls.).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Os réus foram interrogados em seguida. Não houve requerimento de diligências pelas partes.

Em debates orais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu Petronio nos termos da denúncia e a absolvição de Rodrigo por insuficiência de provas. Com relação às penas de Petronio, pediu a fixação acima do mínimo legal, reconhecimento da reincidência do réu Petrônio, afastamento da agravante da calamidade pública, não incidência do redutor e fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento de pena para ambos.

A Defensora constituída pelo réu Rodrigo acompanhou a manifestação ministerial. Subsidiariamente, postulou a incidência do redutor em seu grau máximo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e afastamento da calamidade.

O Defensor nomeado para o réu Petrônio pleiteou a absolvição pela ilegalidade da abordagem policial e também por insuficiência de provas. Pediu, ainda, a desclassificação da conduta do réu, a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime de pena de acordo com o montante de pena a ser fixado.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente em parte.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina por local conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas quando avistaram os réus, juntamente com outras duas mulheres, sendo que inicialmente apenas Rodrigo estava encostado em um carro e quando perceberam a presença da viatura, Petrônio também encostou no carro e as duas mulheres tentaram encobri-los, o que levantou suspeita e motivou a abordagem. Em revista pessoal, com as mulheres nada foi localizado, no tênis do réu Petrônio encontraram uma porção de cocaína, cinco pedras de crack e uma porção de maconha. Nos bolsos da calça de Rodrigo encontraram cerca de R\$ 200 em notas trocadas, bem como uma chave de veículo. Questionado sobre a quantia que tinha em seu poder, respondeu que havia R\$ 150 e posteriormente disse que não sabia ao certo. Em varredura nas proximidades, encontraram na entrada de uma pensão, que fica ao lado de um terreno baldio (cerca de 5/10 metros de onde estavam os réus, segundo Patrick e menos de 20 passos, segundo Nayara), foi encontrada uma sacola escondida entre pedaços de madeira, dentro da qual havia mais porções de maconha, crack e cocaína, com embalagens idênticas às das drogas que estavam com Petrônio. Sobre a chave do carro, Rodrigo disse que era seu veículo e indicou-o, sendo que estava estacionado bem perto. Em revista veicular, acompanhada de perto pelos réus, foi encontrada uma sacola com dinheiro embaixo do banco traseiro, também em notas trocadas. Rodrigo negou que aquele dinheiro fosse dele. Eles estavam bebendo quando foram vistos inicialmente. No local dos fatos, Petrônio disse que a droga era para seu próprio consumo. Apenas no Distrito Policial, após o interrogatório, foram informados pela autoridade policial que Petrônio teria

confessado. Não os conheciam anteriormente. Petronio mora nas proximidades, sendo que a filha dele compareceu já no final da ocorrência. Rodrigo mora em bairro próximo (Cambuci, segundo Patrick). Eles não pareciam estar sob efeito de drogas. Com eles não havia qualquer apetrecho para consumo de drogas. Uma das mulheres era esposa de Rodrigo e a outra disse que apenas os conhecia e estava ali conversando com eles.

Em seu interrogatório o réu Rodrigo negou a prática delitiva. Disse que se dirigiu ao local para encontrar amigos, juntamente com sua esposa, sendo que era feriado e pretendia beber com amigos. Encontrou Petronio no local, o que apenas conhecia de vista. Encontraram com uma amiga do casal chamada Nayara. Saiu de casa com certa quantia em dinheiro, sendo que usou parte do valor para comprar bebida e abastecer o carro, motivo pelo qual não sabia ao certo quanto tinha consigo. Conhecia Petronio apenas de vista. Havia combinado com ele de se encontrarem, mas ele não tinha dado certeza. Acompanhou a revista de Petronio e confirma que com ele foram encontradas drogas. Não o viu usando drogas naquele dia. Quanto ao dinheiro que teria sido encontrado em seu carro, nega que fosse de sua propriedade. Não conhecia os policiais anteriormente.

Em seu interrogatório o réu Petronio negou a acusação que lhe é feita. Disse que mora em frente ao local da abordagem. No dia dos fatos, havia recebido seu pagamento parcial e usou R\$ 80 para comprar 5 porções de crack, 1 de maconha e 2 de cocaína, a R\$ 10 cada porção. Foi para sua casa e saiu novamente, quando encontrou o corréu e começaram a beber juntos. O interrogando estava com R\$ 370. Viu uma viatura passar pelo local e ficou nervoso, solicitando que Rodrigo deixasse entrar em seu carro, onde o interrogando acabou escondendo o dinheiro e fazendo uso de uma porção de cocaína. Saiu e a viatura retornou, vindo a ser abordado. Conhecia os policiais apenas de vista.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu Petronio, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas e prontas para a entrega a usuários, sendo que parte das drogas estavam em poder de Petronio e a maior parte, com idênticas embalagens, estava armazenada em uma sacola próxima de onde ele foi abordado; nervosismo do réu, descrito com clareza por ambos os policiais; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a condição financeira do réu; ausência de demonstração que a droga destinava-se para consumo próprio; a prisão ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico; confissão do réu perante a autoridade policial, circunstância que foi confirmada pelos policiais, que foram informados sobre a confissão pelo Delegado; ausência de qualquer elemento que indique a intenção dos policiais em prejudicar o réu. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câm. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Considera-se que a abordagem policial levada a cabo nestes autos seja regular e não esteja de qualquer forma viciada. Com efeito, os elementos concretamente descritos pelos policiais ouvidos indicam que havia fundada suspeita a ensejar a abordagem e a revista pessoal, nos exatos termos previstos pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Ora, os policiais narraram que o local dos fatos é conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, disseram que o réu Petronio reagiu com muito nervosismo ao avistar a viatura policial, fez menção de se retirar e depois retornou para perto de Rodrigo, sendo que as duas mulheres que estavam próximas tentaram de alguma forma encobri-lo visualmente. Considera-se que tais elementos

sejam suficientes para configurar a fundada suspeita legalmente prevista para dar ensejo à abordagem e consequente revista pessoal ao réu.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que a ré não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Observo que pequenas contradições, não essenciais aos fatos, apenas ratificam a veracidade de seus depoimentos, pois indicam de forma clara que não houve prévio ajuste sobre a versão que deveria ser ofertada, baseando-se seus relatos exclusivamente na memória que têm do dia dos fatos.

Ademais, a versão de Petronio não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, nem mesmo na versão apresentada por Rodrigo, já que Petronio afirma que entrou no veículo de Rodrigo quando a viatura passou pelo local em uma primeira oportunidade, pois ficou nervoso. Mas, tal não foi relatado por Rodrigo. De outra banda, se nervoso ficou porque estava em poder de drogas, porque não as deixou no carro, ao invés do dinheiro, como por ele afirmado? Ademais, Petronio relatou que comprou as drogas e retornou para sua casa. Porque não teria deixado ali as drogas e o dinheiro? Mesmo nervoso com a presença policial, afirma que resolver fazer uso de uma porção de cocaína. Assim, sua versão mostra-se totalmente inverossímil e em dissonância com as provas dos autos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 227/229, que atestou positivamente os efeitos tóxicos dos entorpecentes, além do auto de exibição e apreensão (fls. 19/20).

Irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido comercializando os entorpecentes, pois se trata de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos seus verbos nucleares para sua configuração, sendo que no presente caso tinham em depósito e guardavam, as drogas supramencionadas.

Quanto a Rodrigo, a situação é diversa, pois com ele não foi encontrado qualquer entorpecente. Em seu poder havia apenas dinheiro, que também foi encontrado no carro dele. Mas, inexistem elementos que indiquem de forma concreta que aquele dinheiro era proveniente da venda de drogas. O simples fato de estar ao lado de Petronio, que ora se reconhece que estava na prática de tráfico, não se mostra suficiente para a ele se imputar o mesmo delito. Assim, deve ser absolvido da imputação que lhe é feita por insuficiência de provas.

Não há que se falar em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei nº

11.343/06, pois quantidade de droga não se coaduna com o mero porte para consumo pessoal, não sendo incomum, infelizmente, o tráfico de drogas realizado por usuários para manutenção do próprio vício.

Quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexos causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão. Forçosa, destarte, a condenação do réu Rodrigo nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva dos entorpecentes, em formas diversas (cocaína e crack) encontrados em seu poder, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, tratando-se de drogas com alto poder viciante, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Ademais, Petrônio é portador de mau antecedente perante a 7ª Vara Criminal Central (autos nº 0047997-77.2010.8.26.0050 - trânsito em julgado para a defesa em 08/09/2010 - fls. 60 e pena julgada extinta em 03/04/2014 - fls. 59).

Anoto que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tais condenações como maus antecedentes, uma vez que o E. STF é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Assim, majoro a pena-base em 1/5, ficando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na sequência, ausentes atenuantes, as penas devem ser elevadas em 1/6 diante de sua reincidência (29ª Vara Criminal Central - autos nº 0003882-63.2013.8.26.0050 - trânsito em julgado para a defesa em 01/09/2014 - fls. 68 - pena a cumprir - fls. 62), ficando em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente. Com efeito, o legislador não estabeleceu que apenas a reincidência específica é capaz de afastar a incidência de causa de diminuição de pena, sendo certo que conceito de reincidência é objetivo e legalmente previsto.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, o réu foi surpreendido na posse de quantidade e diversidade relevante de entorpecentes, tratando-se daqueles que maior risco representa para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivos para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que

o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas dos réus são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu PETRONIO EMIDIO DA SILVA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal e ABSOLVER o réu RODRIGO DOS SANTOS CHAVES da imputação de infração ao artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com relação ao réu Rodrigo, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com relação ao réu Petrônio, as mesmas razões que recomendaram sua custódia no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga.

Frise-se, ainda, a sua reincidência e, ainda, tratar-se de réu com pena a cumprir (fls. 62), o que apenas ratifica que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu Petrônio no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu Petronio (fls. 247).

O dinheiro encontrado em poder de Rodrigo deverá ser liberado, mediante preenchimento dos formulários, observando-se que para levantamento pela patrona deverá ser juntada procuração com poderes específicos.

Oficie-se para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido, independentemente do trânsito em julgado.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença com relação ao réu Petrônio. P.R.I.

São Paulo, 14 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA